

1500077-02.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... referentes à contabilidade do tráfico, circunstâncias estas que evidenciariam que o tráfico não seria exercido pontualmente. Deste modo, é de rigor, pela ausência de provas, a absolvição dos acusados, no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06. No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500077-02.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2008732/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22372894 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 73/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2008732 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

ALAN MACHADO SIVILIANO e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP e Art. 35 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 69 "caput" do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

28/03/2022

Réu Preso

Em 28 de março de 2022, às 16:00h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, os réus ALAN MACHADO SIVILIANO e GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA, bem como suas Defensoras Técnicas, DRA. Rosangela Aparecida Xisto Soares OAB 85062/SP e DRA Rúbia Ferrarezi OAB 186769/SP, respectivamente. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Luiz Felipe Bertolasi dos Santos, Mauri Correia Morais (PM) e André Bispo da Silva (PM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com suas Defensoras. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório dos réus. As perguntas foram inicialmente formuladas

pela MMª Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. Os réus ALAN MACHADO SIVILIANO e GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA. devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados criminalmente como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, eis que: 1) no dia 10 de janeiro de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas; 2) no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 16h, na Rodovia SP 127, Km 118, nesta cidade e Comarca de Tatuí, previamente ajustados, agindo em concurso, com unidade de desígnios, identidade de propósitos, traziam consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 200 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 155,75 gramas, 15 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 19 gramas, e 56 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 44 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, os acusados se dedicavam ao tráfico ilícito e, para tanto, traziam consigo grande quantidade de cocaína, para posterior entrega ao consumo de terceiros. Policiais Militares estavam em serviço na Rodovia SP 127, quando avistaram o veículo I/LIFAN 530, Placas FPD6G16, com 3 ocupantes, e deliberaram pela abordagem. Na ocasião, ao receber sinal de parada, o condutor de pronto obedeceu e parou o veículo no acostamento. Durante a abordagem, os policiais identificaram ALAN, que estava na frente, no banco do passageiro, e GUSTAVO, que seguia no banco de trás. Ao volante estava Luiz Felipe Bertolasi dos Santos, motorista de aplicativo, que estava conduzindo os acusados e tudo aparentemente desconhecia. Efetuando revista pessoal, os policiais encontraram 15 porções de cocaína em poder de ALAN, individualmente embaladas e dispostas de modo a facilitar a venda. Com GUSTAVO, os policiais localizaram a importância de R\$ 490,00 em espécie, dinheiro angariado com a venda de entorpecentes, que os acusados praticavam de forma associada. Dando continuidade às diligências, efetuando buscas no veículo, os policiais lograram encontrar 1 mochila no banco de trás, contendo 4 aparelhos de telefone celular, 200 porções de cocaína, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, e 44 "saquinhos" contendo cocaína, drogas que pertenciam aos denunciados e estavam destinadas à venda. Notificados (fls. 117 e 119), os réus apresentaram Defesas Preliminares (fls. 128 e 139/142), procedendo-se, então, o regularmente recebimento da denúncia em 15 de março de 2021 (fls. 241/246). Durante a instrução, os réus foram interrogados, bem como foram ouvidas três testemunhas, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação dos réus nos termos da exordial. Por outro lado, as Defesas Técnicas dos réus pugnaram pela total absolvição dos acusados, sustentando falta de provas, bem como, subsidiariamente, pela concessão de todos os benefícios legais cabíveis a incidir em fase de dosimetria da pena e fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 36/40, bem como certidões a fls. 34/35 e 41/44. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido acusatório merece ser julgado parcialmente procedente. Vejamos: É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor

deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:" (grifos aditados). No entanto, para se que não se confunda o mero concurso de pessoas – de que trata o art. 29 do Código Penal – com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso que o dolo dos agentes que agiram em conluio projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter permanente, estável e duradouro. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes. (...)” (STJ - HC: 214660 SP 2011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013). Neste mesmo sentido, coleciono também o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...)” (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP 0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014)

Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: "(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...)” (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103). Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, noto que, embora haja comprovação de que os acusados exerciam o tráfico de entorpecentes, inexistem provas suficientes de que eles pretendiam perpetrar a narcotraficância em caráter permanente. Isto porque não houve prévia investigação policial, onde fosse mapeado com precisão as divisões de incumbências da suposta associação criminosa, bem como não foi apreendida grande quantidade de entorpecentes ou anotações referentes à contabilidade do tráfico, circunstâncias estas que evidenciariam que o tráfico não seria exercido pontualmente. Deste modo, é de rigor, pela ausência de provas, a absolvição dos acusados, no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06. No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 18/21), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), pelo auto de constatação preliminar (fls. 24/25), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 84/86) e pelas demais provas acostadas nos autos. A autoria de ambos o réus é igualmente evidente e clara, a despeito dos acusados terem negado a participação de Alan. Vejamos: O réu GUSTAVO, em solo policial (fls. 08), manteve-se silente. Em juízo, disse que foi contratado como mula estava passando por necessidades, daí pegou a droga em registro e foi levar até Laranja Paulista. Pegou os dados do Luiz Felipe pelo facebook. Melhor esclarecendo passaram para ele o contato, mas não foi Alan pois nem o conhecia. Não viu nenhuma droga sendo encontrada com Alan. Estava apenas na mochila. Trabalha com pintura. Tem uma filha de 08 anos e um enteado de 04 anos. Já foi processado. Tem residência em Pariquera, já sua família é de Pedreira. Iria até a rodoviária de Laranjal e não sabia com quem iria encontrar. De outro lado, o acusado ALAN, em solo policial (fls. 13), afirmou que, na data dos fatos, estava em sua residência e, por volta das 07:00 horas, seu amigo Felipe foi até sua casa do interrogado para que fossem até a cidade de Registro para buscar o GUSTAVO, que também é seu amigo. Chegaram a

cidade de Registro e GUSTAVO estava na Rodoviária, após o que retornaram para a cidade de Laranjal Paulista. Quando já estavam próximo de Tatuí, foram abordados por policiais rodoviários. Em seu poder, nada de ilícito foi encontrado nem droga e nem dinheiro. Viu os policiais revistarem GUSTAVO, que estava sentado no banco de trás e localizaram drogas no interior da mochila de GUSTAVO. Esclareceu que a corrida foi paga pelo GUSTAVO. Não sabia que GUSTAVO estava portando drogas. Em juízo, disse que era acompanhante do uber. Não havia anda com ele. Quando perguntaram se havia algo com o Gustavo ele ficou quieto e acharam droga na mochila dele. Não conhecia o Gustavo. Fazia viagens com Felipe quando eram viagens longas e fazia companhia para ele. Desconhece essa droga em sua mochila. Talvez os policiais falaram isso por ele ter passagens quando de menor. Nunca foi condenado. Trabalhava com serviços gerais, como pintor, pedreiro. Tem 04 filhos. É usuário. Analisando a autodefesa dos acusados- colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - observo que os réus visaram excluir qualquer participação do corréu Alan, visando certamente afastar a imputação de associação. Vê-se ainda contradições entre o depoimento destes e da testemunha Luiz Felipe. Os réus a todo custo querem fazer crer que eram desconhecidos, já a testemunha Luiz Felipe, que teria servido de motorista para a corrida pontuou que recebeu uma ligação de Gustavo para realizar uma corrida de Registro a Laranjal e indagado sobre como conseguiu o contato, Gustavo teria dito que fora Alan. Assim, tratando-se de um conhecido de Alan, a testemunha Luiz Felipe o chamou para a corrida solicitada pelo amigo. Assim, a negativa de autoria de Alan restou inverossímil, pois sem lastro argumentativo coerente, bem como mostrou-se isolada nos autos, sem qualquer corroboração probatória. Pelo contrário, a prova produzida nesse caderno processual revela que os réus praticaram o tráfico de drogas. De fato, o Policial Militar André Bispo da Silva, em sede policial (fls. 04/05), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, em patrulhamento pela rodovia SP 127, suspeitaram do veículo Lifan na cor marrom, que transitava pela rodovia, tendo em seu interior 03 pessoas. Realizada abordagem na altura do km 118 e realizada busca pessoal nos sujeitos, com o passageiro identificado como ALAN, que estava sentado no banco dianteiro (carona), foi localizado no bolso de sua jaqueta 15 papelotes aparentando conter cocaína. Com o segundo indivíduo, identificado como GUSTAVO, que estava sentado no banco traseiro, foi localizado com ele a quantia de R\$ 490,00 em espécie. Feita busca veicular no interior de uma mochila, que estava no banco traseiro, foi localizada certa quantia de entorpecente, sendo 200 pinos de cocaína e 44 porções em saquinhos de cocaína, além de quatro celulares. Na busca veicular, foi localizada a quantia de R\$ 665,00 pertencente ao motorista. Em juízo, confirmou terem visto o indivíduo do banco de trás abaixar-se e isso motivou a abordagem. Com o indivíduo que ocupava o banco do carona, foram encontradas algumas porções de cocaína e no banco de trás dentro de uma mochila foi encontrado o restante de cocaína, idênticas as que estavam com o passageiro a frente. Convergingo em mesmo sentido, o também Policial Militar Mauri Correia Moraes, em sede policial (fls. 06), corroborou integralmente a versão de seu colega de trabalho. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento pela SP 127 e avistaram o veículo e ao emparelhar no veículo, viram que um dos indivíduos abaixou-se e assim decidiram pela abordagem. Com o indivíduo que estava a frente, no banco do passageiro, na jaqueta, foram encontradas 15 porções. No banco de trás foi encontrada uma mochila com o restante da droga. O indivíduo que estava no banco de trás assumiu a propriedade da droga e da mochila. Perguntas da defesa - 15 porções estavam na jaqueta do réu que estava no banco do carona e atrás a mochila com as drogas. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos policiais, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente os réus ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da

testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Finalmente, a testemunha Luiz Felipe Bertolasi dos Santos, ouvida em solo policial (fls. 07), afirmou que trabalha pelo aplicativo CEVI (transporte de passageiros). Na data dos fatos, por volta das 07:30 horas, pegou o passageiro ALAN na residência dele na cidade de Laranjal Paulista e levou-o para a cidade de Registro, para buscar o amigo dele de nome GUSTAVO. Estavam retornando para a cidade de Laranjal Paulista, quando já estavam próximo da cidade de Tatuí, foram abordados pelos policiais rodoviários. Foram revistados e os policiais localizaram na mochila do rapaz que foram buscar em Registro certa quantidade de cocaína. Não presenciou quando os policiais localizaram droga com ALAN, o qual é conhecido dele por corridas realizadas para ele. Não conhece GUSTAVO. Não sabia que GUSTAVO e ALAN estavam com drogas. Somente sabia que ambos são usuários de cocaína. Recebeu do GUSTAVO a quantia de R\$ 550,00 pela corrida. Somente ficou sabendo que ALAN estava portando droga já na Delegacia. Em juízo, a testemunha disse que conhece Alan que era seu cliente (faz transporte de passageiros) e morava em sua cidade (Laranjal). No

dia dos fatos Gustavo entrou em contato com ele e solicitou uma corrida, sendo que ele se encontrava em Registro. Indagou quem havia passado seu contato e ele disse que era Alan. Depois ligou para o Alan e disse se ele não queria ir junto, caso não estivesse trabalhando, pois ficou com um pouco de receio. Pegaram Gustavo na rodoviária, almoçaram e seguiram para Laranja. Trabalha com Uber e Cevi, mas Gustavo o contratou por Whats up. Desconhecia a existência de droga no local e não sabia o que havia com Alan ou se Gustavo passou droga para ele. Pelo que conversaram Gustavo estava há 03 meses morando em Ilha Comprida e iria visitar os parentes. Eles conversaram sobre festa. Conversaram sobre drogas como usuários. Perguntas da defesa - conhece Alan há 03, 04 meses. Nunca ouviu comentários sobre Alan, sabia que ele trabalhava como servente de pedreiro. Perguntas do juízo - viu os policiais retirarem a mochila de Gustavo, mas na hora não viu encontrarem droga com Alan. Gustavo admitiu a propriedade da droga. Está preso por um assalto. Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que os acusados transportavam e guardavam as drogas apreendidas, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram verossimilmente, a apreensão das drogas, parte com GUSTAVO, outra parcela com ALAN; 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 84/86), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente; e 3) a confissão do réu Alan quanto a propriedade da droga encontrada na mochila. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas porções, própria da venda a varejo; e 3) a não apreensão de qualquer instrumento ou

apetrecho utilizado para o consumo das drogas. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de "cocaína" provoca o "enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação" (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Anoto que a confissão parcial do réu Gustavo não fará incidir a respectiva atenuante, eis que teceu versão inverossímil acerca da ausência de droga com Alan, da participação de Alan e até mesmo quanto a conhecer previamente Alan. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 84/86) e demonstrado que os réus incorreram em verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 - trazer consigo e transportar -, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que

os réus perpetraram o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. I – DO RÉU GUSTAVO: Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. De fato, deve-se ser considerado nesse momento a quantidade e de drogas, bem como sua variedade (200 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 155,75 gramas, 15 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 19 gramas, e 56 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 44 gramas), revelando a maior gravidade dos fatos sub judice. Além disso, observo que o acusado ostenta duas condenações criminais definitivas, de modo que utilizarei uma delas (Proc. 0002533-63.2015.8.26.0435 – fls. 42) como maus antecedentes, e a outra como agravante de reincidência, sem que se incorra em bis in idem. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do E. TJSP: “é plenamente viável o rateio das duas condenações definitivas do réu João entre antecedentes e reincidência, sem incidir em bis in idem, permitindo a correta individualização de sua pena, de acordo com todas as circunstâncias do caso concreto.” (TJSP; Apelação Criminal 1500174-20.2021.8.26.0544; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021). De igual modo, entende o C. STJ (“É firme o entendimento desta Corte Superior de que, em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes” – HC 304.411/RJ, j. 03/05/2018). Por tais motivos, especialmente pelo histórico criminoso significativo e que a condenação anterior configuradora de maus antecedentes também foi por tráfico de drogas, fixo sua pena-base 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Em segunda fase, resta caracterizada a agravante de reincidência, (Proc. 1500114-06.2019.8.26.0548 – fls. 41). Agravo, pois, sua sanção penal em 1/6, gerando a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno definitiva pela ausência de outras causas modificadoras da pena a incidir. Por oportuno, convém destacar a

inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Consigno que a reincidência do réu e seus péssimos antecedentes impedem a concessão da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33, § 3º, c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime fechado, considerando a reincidência do acusado e seus maus antecedentes, bem como a quantidade e variedade de entorpecentes traficados. A tão só quantidade de pena

inviabiliza a concessão do sursis ou dos benefícios previstos no art. 44 do CP. II – DO RÉU ALAN: Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. De fato, deve-se ser considerado nesse momento a quantidade e de drogas, bem como sua variedade (200 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 155,75 gramas, 15 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 19 gramas, e 56 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 44 gramas), revelando a maior gravidade dos fatos sub judice. Por tal motivo, fixo sua pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno definitiva, ante à minguagem de outras causas modificadoras da pena a incidir. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, tratando-se de réu que está sendo processado em outro feito, também pelo exercício da traficância (Proc. 1500390-23.2020.8.26.0315 – fls. 34), elemento caracterizador de dedicação a atividades criminosas, resta inviabilizada a concessão da benesse em questão. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: “É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.” (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33, § 3º, c.c. o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime fechado, considerando sua personalidade delitiva, bem como a quantidade e variedade de entorpecentes traficados. Ademais, observo que as circunstâncias que justificaram a fixação do regime prisional mais severo também impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A tão só quantidade de pena inviabiliza a concessão do sursis. III – DAS DISPOSIÇÕES COMUNS: Por derradeiro, quanto a ambos os acusados, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: “No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena”. (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-

05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). IV – DO DISPOSITIVO E CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE Procedente a pretensão punitiva para: 1) condenar o réu GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; 2) condenar o réu ALAN MACHADO SIVILIANO, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal; e 3) absolver os réus da imputação de infringência ao disposto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Indefiro o Apelo em Liberdade, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão provisória dos acusados. E mais, considerando que ambos ostentam a personalidade criminosa (com passagens criminais por envolvimento com a traficância), bem como que GUSTAVO é reincidente, verifica-se que, soltos, esses acusados certamente tornarão a delinquir. Por tal razão, para garantir a ordem pública, deve ser mantida a segregação cautelar deles em caso de recurso. E não se venha alegar a situação de calamidade pública decorrente da doença COVID 19, gerada pela infecção do vírus sars-cov-2 ("coronavírus"). Trata-se de tema que reclama prudência judicial no exame das medidas cautelares pessoais, em especial, as prisões preventivas e temporárias. Isso porque, se é fato que as aglomerações de pessoas podem acelerar o contágio da doença e sua disseminação, também é verdade que a libertação indiscriminada dos presos, além de implicar indiscutível prejuízo à manutenção da segurança pública e da aplicação da lei penal (já que há o indiscutível risco de, em tese, praticar novos delitos ou por-se em fuga), também poderá propiciar, por esse fluxo acentuado de pessoas, maior transmissão da enfermidade. É dizer, pode ser que o preso, agora libertado, já esteja infectado, mas em quadro assintomático (o que, segundo dados científicos, pode demorar até 2 semanas ou nem mesmo se manifestar), o que proporcionará a infecção de seus familiares e outras pessoas com quem tiver contato. Outrossim, em estabelecimentos prisionais, onde o acesso de pessoas é controlado e, por ora, proibido, há menor probabilidade ser contaminado do que, em liberdade, saindo as ruas, onde não se tem controle sob a mobilidade dos cidadãos. Dito de outro modo, se a intenção é preservar a saúde do preso, é possível que, em liberdade, por não haver restrição e/ou controle de sua mobilidade, tenha maior possibilidade de contrair a doença do que preso, onde o acesso de pessoas é restrito e, por ora, proibido. O que se quer dizer, em síntese, é que a alegação de pandemia não conduz, invariavelmente, a soltura do preso. Devem ser analisadas outras peculiaridades do caso concreto. In casu,

os elementos acima apontados denotam que é o caso de manutenção da prisão preventiva, o que não se altera com a situação de calamidade pública gerada pelo coronavírus. Até porque não se tem notícia de que há infectado no estabelecimento prisional em que se acham reclusos os réus, tampouco que esses contraíram a doença ou que integrem grupo de risco. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram recolhidos. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento, bem como arquivem-se os autos. Isentos os acusados do pagamento das custas processuais, concedendo-lhes os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que foram assistidos nos autos por defensor dativo. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intimem-se os réus para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, determino a perda do bem apreendido (R\$ 490,00 em dinheiro – fls. 94), em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminosa. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP. Pelas Defensoras

dos réus e pelos réus foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelos réus, saindo os Defensores, desde já, intimados a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 121/122). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA